

1500219-98.2022.8.26.0605

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... comum que usuários adentrem ao mundo do tráfico justamente para sustentar o vício, por ser a atividade ilícita extremamente lucrativa, tendo sido esta, inclusive, a alegação de Robinson.

Restam como pontos a serem analisados o caráter interestadual do tráfico e o delito de associação para o tráfico.

Quanto ao primeiro ponto, causa de aumento prevista no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500219-98.2022.8.26.0605 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500219-98.2022.8.26.0605

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164847/2022 - DEL.SEC.ANDRADINA, 25616692 -

DEL.SEC.ANDRADINA, 2164847 - DEL.POL.CASTILHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON LUIS ROCHA e outro

Réu Preso

O Ministério Público ofereceu denúncia contra EMERSON LUIS ROCHA e ROBINSON ANTONIO SANCHES imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Narra a denúncia que no dia 18 de junho de 2022, por volta das 22h30min, na Rodovia Marechal Rondon, na altura do km 665, na cidade de Castilho, nesta comarca de Andradina: EMERSON LUIS ROCHA, qualificado às fls.08, 29/30, 90 e 98; e ROBINSON ANTONIO SANCHES, qualificado a fls.09, 23/24, 91 e 99 dos presentes autos; atuando em concurso e com unidade de desígnios, adquiriram em outro Estado da Federação, traziam consigo e transportavam, para fins de tráfico, 08 tijolos de "maconha", com peso aproximado de 4,5kg, e uma porção de cocaína, com peso de 0,3g (cf. autos de constatação provisórios às fls.100/101, 102/103 e 104/105 e laudo de exame químico-toxicológico de fls.199/201), substância esta entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em em 29 de julho de 2022, em decisão de fls.352/355. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa do corréu Robinson Antônio Sanches requereu a absolvição em relação ao delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas e, quanto ao restante da acusação, afastamento da causa de aumento relativa à interestadualidade, consideração da confissão e aplicação da pena com valoração das circunstâncias pessoais favoráveis do réu, em regime inicial semiaberto; por sua vez, a d. Defesa de Emerson Luís Rocha requereu igualmente absolvição do delito de associação para o tráfico, assim como da imputação de tráfico de drogas; de forma subsidiária requereu afastamento da causa de aumento, fixação da pena no mínimo legal, aplicação do redutor do § 4º, regime inicial benéfico e direito de apelar em liberdade.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela parcial procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fls.01/03 e boletim de ocorrência de fls.10/14, termo de depoimento de fls.04/07, imagens de fls.92/97, laudos periciais de fls. 199/201 e 357/360, 361/363, fls. 377/399), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada, pelos elementos já indicados, prisão em flagrante e pelos consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

Os policiais militares Willian Calister de Almeida e Adão Marcos Rezende da Silva narraram que estavam em patrulhamento nas proximidades do trevo de Castilho e ao adentrarem em um posto de gasolina observaram uma motocicleta com placa de Lavínia. Portaram-se de maneira bastante nervosa, o que ocasionou a abordagem. Realizada a abordagem e busca, nada de ilícito foi encontrado. Foram indagados separadamente sobre o destino e relataram que estavam saindo de Lavínia e deslocando-se ao rancho da Vila dos Operadores. O nervosismo causou estranheza, mas foram liberados e acompanhados a distância. A longa distância, passaram a acompanhá-los e viram que eles tomaram destino diverso, seguindo para Três Lagoas-MS. Ficaram aguardando por cerca de meia hora e avistaram o veículo retornando, dando sinal de parada, o que foi de pronto obedecido. Foi encontrado com Robinson 6 tijolos de maconha. Com o garupa foi encontrado outros dois tijolos de maconha mais uma porção de cocaína no bolso da blusa. Separadamente, eles disseram que uma pessoa da cidade de Mirandópolis havia feito a encomenda da droga e que eles ganhariam R\$ 400,00 pelo transporte. Questionados sobre passagens anteriores, Robinson disse que já havia sido condenado por tráfico e o Emerson por furto.

Interrogado, o réu Robinson confessou o tráfico, mas negou a associação com Emerson. Disse que o conheceu há dois meses, usando drogas juntos. Como estava em abstinência de droga, concordou em ir buscar as drogas para uma pessoa de Mirandópolis, sendo que receberia o pagamento em drogas. Recebeu as drogas antes da barragem da CESPE, ou seja, antes da fronteira. Presume que a pessoa tenha trazido as drogas de Três Lagoas-MS. Trabalhava à época como folguista em plantão de home care, sendo que recebia R\$ 110,00 de diária. É usuário de crack e maconha.

Por sua vez, o acusado Emerson, foi no mesmo sentido, negando a associação com Robinson, e divergindo apenas com relação aos ganhos a respeito da empreitada.

Confirmou que receberia R\$ 200,00 e que Robinson ficaria com R\$ 200,00.

Com efeito, o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 diz que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Na hipótese a prática do tráfico é indubitável, já que os acusados foram detidos em poder de quatro quilos e meio de maconha, quantidade exorbitante e que jamais poderia ser para uso próprio, tanto que confessaram o delito. Apenas a título de

argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente (TJSP, ACr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j. 26/10/2017), sendo que a quantidade encontrada seria então suficiente para a confecção de até 9.000 cigarros da droga.

Por sua vez, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de quaisquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgado em 04/08/2015).

Outra questão a ser ponderada é que as posições de usuário de drogas e traficante não são excludentes entre si. Em outras palavras, mesmo que o réu seja efetivamente usuário de drogas isso não é impeditivo para o reconhecimento do delito de tráfico – o usuário pode muito bem também ser vendedor ou, ainda, o vendedor ser usuário. Corroborando tal raciocínio: “a alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJ 101/498). Aliás, é comum que usuários adentrem ao mundo do tráfico justamente para sustentar o vício, por ser a atividade ilícita extremamente lucrativa, tendo sido esta, inclusive, a alegação de Robinson.

Restam como pontos a serem analisados o caráter interestadual do tráfico e o delito de associação para o tráfico.

Quanto ao primeiro ponto, causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, inexistem dúvidas de sua caracterização.

Veja-se que os réus estavam no município de Castilho (último município antes da fronteira com o Mato Grosso do Sul na Rodovia SP-300) e seguiram na dita rodovia em direção a Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Do local onde estavam (Posto Trucks) até Três Lagoas a distância é de apenas 30 quilômetros. Os policiais afirmaram que os esperaram retornar, por cerca de 1 hora, sendo que o horário é compatível com a ida dos réus até o Mato Grosso do Sul e retorno a São Paulo.

Também não faria sentido que saíssem da última cidade do Estado de SP (Castilho), com direção ao Mato Grosso do Sul, para encontrar uma pessoa em plena rodovia. A única possibilidade viável e plausível é de que cruzassem a fronteira.

Ademais, é certo que, na forma da súmula 587 do STJ, “para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”. Equivale a dizer: ainda que tivessem recebido a droga antes da fronteira, é certo que sabiam que a pessoa que entregou o entorpecente era oriunda do Mato Grosso do Sul.

E, por último, há um elemento objetivo a indicar que de fato os réus foram até Três Lagoas e que faltaram com a verdade em seus interrogatórios. No relatório de fl. 393, o próprio acusado Robinson fala para seu interlocutor, o qual intermediava a entrega das drogas, que estava no posto de gasolina BR Mania (da rede Petrobrás), em frente ao “Cristo”. Em uma busca no Google (inclusive pela ferramenta Street View), pode-se localizar o Posto Rebucci, justamente da bandeira Petrobrás (a qual tem lojas de conveniência com título “BR Mania”), localizado em frente ao Cristo Redentor da cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Av. Cap. Olinto Mancini, 3270 - Jardim Alvorada, Três Lagoas. O Cristo, por sua vez, fica no numeral 2879 da mesma avenida, poucos metros adiante, portanto.

Para que não fique nenhum tipo de dúvida, colaciono a foto retirada do Google Street View nesta data, com destaque para a Loja BR Mania e para o Cristo Redentor, ambos circutados em vermelho:

Superado tal ponto, por fim, entendo que, apesar da gravidade do fato, não existem provas seguras para reconhecimento da associação para o tráfico entre os corréus Robinson e Emerson. Apesar do relatório de fls. 377/399 indicar prática corriqueira de tráfico por Robinson, é certo que não há qualquer elemento objetivo a dar suporte à acusação de que teriam um vínculo associativo para praticar o crime,

sendo que o mero concurso de agentes ou a gravidade dos fatos não é suficiente para tanto; mostra-se necessária a demonstração de um plus em relação ao concurso, justamente o ânimo de se associar para a prática do tráfico, ainda que em apenas um ato, o que inócorre no caso.

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de tráfico de drogas com caráter interestadual é procedente, cabendo a condenação dos réus, com solução diversa e oposta quanto ao delito de associação para o tráfico. Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima 1/8 sobre oito anos, o que representa um ano.

Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos. Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça).

Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto (1/6), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a

pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de 1/6 será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

"2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais". E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base".

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

1 - Emerson Luís Rocha

Na primeira fase, entendo deva a pena-base ser exasperada em razão da quantidade de drogas, sendo maior a agressão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. A rigor, não seria sequer isonômico estabelecer pena-base igual para o réu e para outros apenados flagrados com quantidade de droga sensivelmente menor. Ressalto que a pena parte do mínimo legal (5 anos) e a este patamar serão somados os montantes das frações encontradas a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a partir da pena mínima.

NÃO SE TRATA DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO TERMO MÉDIO (O QUAL FARIA A PENA-BASE PARTIR DE 10 ANOS E NÃO DO MÍNIMO), TAMPOUCO DE ERRO ARITMÉTICO.

Trata-se de utilização de distinta base de cálculo para encontro das frações de mudança da pena, utilizando-se o resultado do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a pena mínima, critério este que considera a gravidade do crime de forma global conforme estipulada pelo legislador e mostra-se mais proporcional ao juízo prévio feito pelo parlamento sobre a natureza do crime (caso contrário, crimes com pena mínima igual e pena máxima diversas, como o estupro e o homicídio, o furto qualificado e a corrupção passiva, etc, teriam idêntico apenamento, o que não se mostra de fato adequado, pois o legislador já estabeleceu distinção prévia de gravidade, a ser observada pelo julgador; já crimes com penas mínimas muito elevadas, teriam exasperações exageradas, como a extorsão mediante sequestro com resultado morte, com pena mínima de 24 anos).

De toda forma, destaco novamente que o tópico acima ("critérios para fixação da pena") estabelece as justificativas pelas quais a individualização da pena resta melhor assegurada por esta forma de cálculo, que é diferente do padrão normalmente adotado (mais cômodo para cálculos, mas que desconsidera inúmeros fatores de proporção e postulados a respeito da prevalência dos critérios de lei sobre critérios subjetivos), mas que é referendado por argumentos racionais e também pela jurisprudência do STJ (HC 498586/SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020 e AgRg no

REsp 1704633/TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019).

Feito novamente tal esclarecimento, adiciono à pena mínima (5 anos) o montante de 1 anos e 3 meses de reclusão (além de 125 dias-multa), equivalente a 1/8 de 10 anos (intervalo de pena estabelecido pelo legislador ao considerar globalmente a gravidade do crime, com pena mínima de 5 e máxima de 15) e estabeleço a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o acusado confessou o crime, circunstância levada em conta para a formação da convicção sobre a condenação. Na esteira de já consolidada jurisprudência do STJ (HC n. 365.963/SP), incide a atenuante, fazendo com que a pena retorne ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento relativa ao caráter interestadual da conduta, em 1/6, levando a pena a 5 anos e 10 meses e 583 dias-multa.

Por fim, à míngua de comprovação de efetiva e concreta dedicação a atividades criminosas, ausentes antecedentes ou prova de vinculação a organizações criminosas, entendo viável a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, mas em seu patamar mínimo, de 1/6. Anoto que o STJ possui entendimento consolidado no sentido da possibilidade de modulação da fração a ser utilizada com base em circunstâncias que não sejam preponderantes e não utilizadas na primeira fase (STJ. 5ª Turma. REsp 1.985.297-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 29/03/2022). Isso porque as circunstâncias do crime indicam uma maior reprovabilidade da conduta. Se inexistem parâmetros objetivos para se estabelecer a associação, é inegável que os réus agiram de forma planejada e para consecução de crime de maior gravidade que a comum. Além da longa distância percorrida, tiveram de operacionalizar e acondicionar vários tijolos de maconha para trazê-los em conjunto para distribuição nas cidades da região. Certo que referida operação desborda da normalidade e deve ser valorada negativamente no sentido de permitir a redução apenas em patamar mínimo.

Assim, fixo a pena em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa.

O regime inicial, tendo em vista a gravidade em concreto do crime, circunstâncias desfavoráveis nas primeira e terceira fases, deve ser o fechado. Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena.

2 - Robinson Antônio Sanches

Na primeira fase, além dos fundamentos já estabelecidos na dosimetria do corréu Emerson sobre a quantidade de drogas, observo que o acusado Robinson é duplamente reincidente (fls. 439/442), sendo que uma das condenações então será utilizada na primeira fase, a título de antecedentes criminais. Cabe a exasperação na primeira fase por duas vezes, em 1/4, portanto.

Ressalto que a pena parte do mínimo legal (5 anos) e a este patamar serão somados os montantes das frações encontradas a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a partir da pena mínima.

NÃO SE TRATA DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO TERMO MÉDIO (O QUAL FARIA A PENA-BASE PARTIR DE 10 ANOS E NÃO DO MÍNIMO), TAMPOUCO DE ERRO ARITMÉTICO.

Trata-se de utilização de distinta base de cálculo para encontro das frações de mudança da pena, utilizando-se o resultado do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a pena mínima, critério este que considera a gravidade do crime de forma global conforme estipulada pelo legislador e mostra-se mais proporcional ao juízo prévio feito pelo parlamento sobre a natureza do crime (caso contrário, crimes com pena mínima igual e pena máxima diversas, como o estupro e o homicídio, o furto qualificado e a corrupção passiva, etc, teriam idêntico apenamento, o que não se mostra de fato adequado, pois o legislador já estabeleceu distinção prévia de gravidade, a ser observada pelo julgador; já crimes com penas mínimas muito elevadas, teriam exasperações exageradas, como a extorsão mediante sequestro com resultado morte, com pena mínima de 24 anos).

De toda forma, destaco novamente que o tópico acima ("critérios para fixação da pena") estabelece as justificativas pelas quais a individualização da pena resta melhor assegurada por esta forma de cálculo, que é diferente do padrão normalmente adotado (mais cômodo para cálculos, mas que desconsidera inúmeros fatores de proporção e postulados a respeito da prevalência dos critérios de lei sobre

critérios subjetivos), mas que é referendado por argumentos racionais e também pela jurisprudência do STJ (HC 498586/SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020 e AgRg no REsp 1704633/TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019).

Feito novamente tal esclarecimento, adiciono à pena mínima (5 anos) o montante de 2 anos e 6 meses de reclusão/detenção, equivalente a 2/8 de 10 anos (intervalo de pena previamente estabelecido pelo legislador ao considerar globalmente a gravidade do crime, que tem pena mínima de 5 e máxima de 15 anos, com intervalo de 10, portanto) e estabeleço a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o acusado é reincidente (fls. 439/442) mas confessou o crime, circunstância levada em conta para a formação da convicção sobre a condenação. Na esteira de já consolidada jurisprudência do STJ (HC n. 365.963/SP), neutralizam-se as circunstâncias.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do caráter interestadual do delito, em 1/6. Com a operação, a pena vai a 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa. Duplamente reincidente (inclusive por tráfico) e com clara dedicação a atividades criminosas (veja-se o relatório de fls. 377/399 relativo ao aparelho celular do acusado, que frequentemente negocia drogas), inviável a aplicação do redutor. Regime inicial fechado, ante a quantidade de pena, dupla reincidência e circunstâncias desfavoráveis.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação para CONDENAR os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às seguintes penas: 1) EMERSON LUIS ROCHA: 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa; e 2) ROBINSON ANTONIO SANCHES: 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa, ambos em regime inicial fechado e calculado o dia-multa em seu mínimo legal. ABSOLVO os acusados do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Os réus responderam ao processo presos e foram condenados a penas altas, por crime grave. Formada a culpabilidade em juízo de certeza, não vislumbro razões para que sejam postos em liberdade, permanecendo os motivos para a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. Recomendem-se-os no presídio em que se encontram e expeça-se guia de recolhimento.

Vale a presente como reavaliação da preventiva, na forma do 316, parágrafo único, do CPP.

À mingua de cálculo sobre o lapso de pena cumprida e dados sobre o comportamento dos acusados, eventual juízo sobre a progressão de pena deve ser efetuado pelo juízo das execuções.

Condeno os réus ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade, que fica aqui deferida ante as condições socioeconômicas dos réus. Com o trânsito em julgado: i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, iii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento. Caso tal providência já não tenha sido determinada, determino a destruição das drogas apreendidas.

Com relação aos bens apreendidos, tratando-se de objetos utilizados para a prática do crime de tráfico, determino seu perdimento à União (revertendo-se ao Funad), na forma do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e art. 63 e seguintes da Lei 11.343/06, além do Recurso Extraordinário 638.491. Caso não haja interesse federal, fica autorizada a destinação ao Município, seja para doação, seja para destruição ambientalmente correta.

Publique-se. Intime-se na forma legal.

Andradina, 03 de outubro de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)